

SENTENCIA NUMERO: 179- 2/12/04

En la ciudad de Córdoba a días del mes de del año Dos Mil CUATRO se reunieron los Señores Vocales de la Excma. Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial y en presencia de la Secretaria del Tribunal, a fin de dictar sentencia en Acuerdo Público en los presentes autos caratulados "**RENOVELL FRANCISCO FERNANDO C/ RIBAS SOMAR DANIEL GUSTAVO Y OTRO - EJCUTIVO PARTICULAR**", con motivo del recurso de apelación interpuesto por el demandado, en contra de la Sentencia N° 202, del 19-5-03, del Juzgado de Primera Instancia y 1º Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad y que resuelve: I) Rechazar el incidente de nulidad procesal planteado por el apoderado de Daniel Gustavo Ribas Somar, con costas. Establecer que la participación de la Dra. Natalia M. Galasso lo es en los términos del Considerando N° IV) infra del presente.- II) Regular los honorarios profesionales del Dr. Ricardo Javier Mancini en la suma de pesos un mil quinientos (\$ 1.500) y los del Dr. Mario Mangiante en la suma de pesos quinientos (\$ 500). Protocolícese. FDO: Maria Mónica Puga de Juncos.-----

Seguidamente se fijaron los siguientes cuestiones a resolver:-----

Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación interpuesto?-----

Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamento corresponde?-----

Conforme al sorteo oportunamente realizado los Señores Vocales emitirán su voto en el siguiente orden: Dr. Raúl E. Fernandez, Dr. Miguel Angel Bustos Argañarás y Dra. Cristina Gonzalez de la Vega de Opl.-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAUL E.

FERNANDEZ, DIJO:-----

I) Contra la sentencia cuya parte resolutive se transcribe más arriba ha apelado la parte demandada, fundando sus disensos en esta Sede, argumentos que han sido respondidos por la parte contraria.

Firme y consentido el decreto de autos, queda la causa en estado de resolver.-----

II) El primer agravio del demandado se refiere al rechazo del recurso de reposición interpuesto contra el decreto de fecha 29 de julio del año dos mil dos y que fuere resuelto por auto número setecientos cuarenta y uno de fecha 17 de septiembre del año dos mil dos, por medio del cual se disponía pasar los autos a estudio para resolver.-----

El segundo agravio apunta al rechazo del incidente de nulidad deducido con fundamento en la falta de participación de quien representa a la parte actora en el juicio.-----

Por último y en relación a la sentencia dictada en autos, se queja pues la señora Juez a quo ha rechazado la excepción de inhabilidad de título opuesta y le ha impuesto las costas en su totalidad a su parte.-----

III) Ingresando al estudio de las constancias de autos, cuadra en primer término y por razones metodológicas analizar el agravio referido al rechazo del incidente de nulidad articulado (arg. arts. 515 y 559 inc. 1° del CPC).-----

Analizadas las constancias de autos me pronuncio por el rechazo del agravio propuesto.-----

En efecto, tal como lo adelantara la sentenciante, conclusiones que por otra parte comparto, se oponen a su admisibilidad, razones de índole formal cuya verificación en la especie derivan en la innecesariedad del análisis de cualesquiera consideración sustancial en torno a su procedencia.-----

El instituto de la preclusión enerva la viabilidad del planteo nulidificatorio atento la extemporaneidad de su introducción al proceso.-----

Las claras previsiones del art. 78 primer párrafo del CPC, que consagra con carácter fatal el plazo de interposición de la pretensión nulidificatoria, bajo el apercibimiento consagrado

ritualmente por el mismo artículo en su párrafo segundo, inc. 1°, conducen al rechazo formal de aquella pretensión. Ello así toda vez a más de los argumentos expuestos por la sentenciante, conforme se desprende de las constancias de autos, la accionada adquiere cabal conocimiento de los actos que hoy se pretende invalidar, a partir de la notificación prevista en el art. 153 del CPC, que dispone que salvo los casos en que proceda la notificación a domicilio, las resoluciones se considerarán notificadas, por ministerio de la ley, el primer martes o viernes posterior al día en que hubieren sido dictadas, o el siguiente hábil, si alguno de aquellos fuere inhábil. De lo que se desprende que existiendo en autos decretos notificables de este modo (fs. 42 vta. entre otros) la parte ha quedado notificado de los actos ejecutados en el proceso con mucha anterioridad a la interposición del incidente en análisis.-----

Habiendo pues transcurrido con exceso el término legal previsto por la norma ritual citada, el planteo de nulidad deviene extemporáneo.-----

Si la parte que comparece a juicio y efectúa peticiones no actúa con la buena fe diligencia requerible al buen litigante que le exigía examinar las constancias de la causa para establecer si había sido correctamente desarrollada conforme los cánones formales, luego no puede pretender invalidar las mismas.-----

IV) Por otro costado, el recurrente no se hace cargo del otro argumento central expuesto por la señora Juez a quo a los fines de rechazar el planteo nulidificatorio, cual fuera, la falta de agravios del peticionante.-----

Así, la señora Juez a quo ha puesto de manifiesto que "por aplicación del principio de trascendencia se arriba a igual siguiente conclusión. Es que la potestad jurisdiccional de proveer o denegar peticiones lo es en función de la correcta gestión del proceso que debe custodiar, y en la especie la decisión de admitir o denegar la participación como apoderada de la mencionada letrada se vinculaba a

la regularidad del acto por el cual se le confería mandato y su efectiva acreditación en autos. Entonces, si el nulidicente no demuestra que existen deficiencias del tipo indicado - defectos en el poder o falta de acreditación del mismo - tales que imponían la denegación de la participación pretendida, la nulidad que denuncia importa una pretensión genérica que no satisface el requisito del art. 77, Ley 8465. Frente a lo señalado queda expuesto que carece de sustento real la pretendida violación al derecho de defensa en juicio pues la pérdida de la posibilidad de producir prueba de la que se queja se relaciona con su propia estrategia procesal cuestión resuelta en pronunciamiento de fecha..." con lo cual el mismo queda firme y el agravio se rechaza.-----

V) Habiéndose analizado lo atinente al rechazo del incidente de nulidad cuadra ingresar al análisis del segundo agravio, referido éste, al rechazo del diligenciamiento de la prueba informativa oportunamente ofrecida.-----

El recurrente se queja en esta Sede pues la señora Juez a quo ha rechazado el recurso de reposición interpuesto contra el decreto de fecha 29 de julio del año dos mil dos, y que fuere resuelto por auto número setecientos cuarenta y uno, de fecha 17 de septiembre del año dos mil dos, por medio del cual se disponía el decreto de autos a los fines de resolver la causa, argumentando que aún no se había clausurado el período de prueba.-----

De los presentes obrados se desprende que dicho agravio corre la misma suerte del anterior.-----

En efecto, ante la denegatoria del recurso de reposición en la Sede anterior, el recurrente pudo replantear la cuestión en esta Sede (art. 515 y 559 inc. 1º CPC).-----

Sobre el particular, valer recordar lo dispuesto por los arts. 515 y 559 CPC, en donde, según el tipo de juicios que nos ocupa, (ejecutivo) la regla es que no procede la apelación inmediata en la instancia anterior - anterior a la sentencia-. El replanteo que

menciona la norma indica que la cuestión se posterga hasta la oportunidad en que el expediente se encuentre en la alzada. (Conf. Vénica, Oscar Hugo, Código Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, pag. 480).-----

Pero es del caso que para poder ejercer la facultad de replantear la cuestión en la Alzada conforme los dispone el art. 375, inc. 2 a) y c) del CPC, era necesario solicitar previamente la apertura a prueba de la causa, sin perjuicio del análisis posterior en cuanto a su procedencia, que el recurrente no hizo, con lo cual no puede analizarse la justeza del auto que resuelve dicha reposición, quedando firme el mismo. Vale recordar la normativa legal citada en cuanto es aplicable al caso la que dispone, inc. 2 c) establece "Cuando en juicio abreviado o ejecutivo se hubiere denegado indebidamente la apertura a prueba o alguna medida de prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores para el primero". No habiéndose utilizado el carril adecuado a los fines de hacer valer su derecho se rechaza el agravio. Esto así pues la apertura a prueba en la alzada está estructurada, para el caso del juicio ejecutivo, como la vía apta para enmendar el error que se dice cometido, la norma especial deroga a la general (art. 371 C.P.C.).----

VI) Por último resta por analizar los agravios referidos a lo resuelto por la sentenciante respecto al fondo del asunto y resuelto mediante la sentencia impugnada.-----

En esta Sede se queja el recurrente pues la señora Juez a quo ha rechazado la excepción opuesta al progreso de la acción, esto es la inhabilidad de título.-----

Ingresando al análisis de la queja del recurrente cuadra señalar que la excepción de inhabilidad de título aparece bien rechazada.-----

Le agravia la sentencia en cuanto la señora Juez a quo soslaya sin argumentación alguna la actitud contraria a la buena fe puesta de manifiesto por la actora, al ejecutar el cheque por al

causal de falta de fondos, cuando en realidad ha sido rechazado por denuncia policial. Alega que su parte no efectuó la denuncia policial y que el actor resulta ser un tercero cuya tenencia del valor ejecutado no surge tan nítida como se pretende en autos. Asimismo alega no haber vinculación alguna entre acreedor y deudor.-----

Es menester señalar que el apelante centra la cuestión en discutir sobre el origen causal del título que se pretende ejecutar, invocando la posesión ilegítima del cheque para poder discutir la cuestión causal.-----

Vale recordar que debido a los caracteres esenciales que poseen los papeles de comercio - cheque- y a los fines de tutelar los valores de la certeza, celeridad, y seguridad en la adquisición y negociación, la ley procesal impone que cuando la acción cambiaria es ejercida por vía ejecutiva (rigor procesal), otorga una mayor eficacia al cobro intentado, pues el ejecutado no podrá valerse de las defensas fundadas en la causa de la obligación cambiaria que asumió. O sea, la prescindencia no sólo será subjetiva (autonomía) sino, además, objetiva (abstracción), aun cuando el ejecutante sea el sujeto relacional en forma directa. Todo ello brinda una mayor posibilidad de satisfacción de la pretensión reclamada al acreedor cambiario, sin perjuicio de que se lo otorgue al deudor ejecutado, la posibilidad de invocar, en un juicio de conocimiento, las defensas sustanciales que estime convenientes.-----

Ya he manifestado en otras oportunidades que comparto la jurisprudencia y doctrina dominantes sobre el particular, que acuerdan respuesta negativa a la posibilidad de discusión causal en el juicio ejecutivo, porque de lo contrario se desvirtuaría el carácter sumario del proceso compulsorio, con clara trascendencia negativa en el tráfico negocial.-----

No es óbice a ello, la denuncia policial, ni quien la haya efectuado, ya que el cheque motivo de los presentes reúne todos los requisitos establecidos por el art. 2 de la ley 24.452, y el

accionante al ser poseedor del título y figurar como beneficiario del derecho en él incorporado, reviste la condición de legitimario cambiario para reclamar el respectivo crédito, tornando inmune al instrumento ante la defensa de inhabilidad de título basada en una denuncia de robo (C.Civil y Com. San Martín, sala II, abril, 06/1.999 en re "González, Horacio c/ Artex S.A.- LL Bs AS. 1.999- 863; en igual sentido CNCom., Sala A, mayo 31-1.999, en re "Reyman S.A. c/ Agro Industrias Internacionales y otro- LL-1.999-E-514). A más de ello, se sostiene que el extravío del cheque no es oponible al ejecutante ni priva al mismo de su derecho a exigir en juicio ejecutivo el cobro de la deuda instrumentada en el documento, careciendo de relevancia que el excepcionante invoque la denuncia policial de la pérdida (C7°CyCom.Cba, 1.999/07/02, in re: "Hurtado, José A. c/ Divo Guenem-LLCba, 2.000-946.).-----

En síntesis, ha dejado sentado el Alto Cuerpo Provincial in re "Winer, Ernesto c. Norberto E. Marty- ejecutivo- Recurso de revisión, 13.946- T.S.J., Sala CCCba, 04/02/97, Sentencia n°1), que aún descalificado como título cambiario el documento en base al cual ha sido despachada la ejecución, debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título si el documento contiene la obligación exigible y no condicionada de pagar una suma líquida o liquidable, a cargo del demandado y a favor del accionante, y el demandado no negó la firma que se le atribuye ni opuso defensas que descalifiquen la ejecutividad del título en función del art. 819 inc. 1° del CPC. Esta es la solución propiciada por calificada jurisprudencia (Cám. Nac. Com. en pleno, 22/09/81, LL, 1981, D, pag. 254).-----

Para el supuesto de autos, el demandado no rechazó la autoría de la firma, no desconoció el contenido del documento, a pesar de negar la deuda cuestionada en autos. La circunstancia de no desconocer la firma al tiempo de excepcionarse, lo involucra en el supuesto mencionado anteriormente de la resolución emanada del Alto Cuerpo.-----

VII) Relativo a la condena en costas efectuada por la sentenciante cuadra señalar que el apoderado de los demandados si bien expresó que la resolución causaba agravios a ambos demandados luego hizo hincapié respecto a las impuestas a la codemandada señora María Marta Gabriela Berisso, como surge del escrito de expresión (fs. 85/88).-----

Si bien esta Cámara no puede modificar el acogimiento del allanamiento como modo anormal de conclusión del proceso (pues a su respecto no hay agravio para las partes), sí tiene facultades para modificar la imposición de costas.-----

Esto así pues ese allanamiento no cumplía con todos los recaudos del art. 131 del C.P.C., a fin de liberar de costas al accionante, por lo que en mi opinión corresponde revocar parcialmente la resolución eximiendo de costas a la codemandada María Marta Gabriela Berisso.-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR MIGUEL ANGEL BUSTOS ARGANARAS, DIJO:-----

Que adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal de Primer Voto, en consecuencia voto en igual sentido.-----

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA CRISTINA GONZALEZ DE LA VEGA DE OPL, DIJO:-----

Que adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal de Primer Voto, en consecuencia voto en igual sentido.-----

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR RAUL E. FERNANDEZ, DIJO:-----

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, debiendo confirmarse el decisorio de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravios, con la salvedad de lo atinente a la imposición de costas atribuida a la codemandada María Marta Gabriela Berisso, la que debe ser eximida de las mismas.-----

Costas en esta Sede a cargo de la parte vencida.-----

Regular los honorarios al Dr. Ricardo Javier Mancini en el 35% de la escala media del art. 34 de la ley 8226 (arts. 34, 36, 37 y conc. de la ley 8226).-----

No regular los honorarios al Dr. Mario Mangiante atento lo dispuesto por el art. 25 de la ley citada.-----

ASI VOTO. -----

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR MIGUEL ANGEL

BUSTOS ARGANARAS, DIJO:-----

Que adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal de Primer Voto, en consecuencia voto en igual sentido.-----

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA CRISTINA

GONZALEZ DE LA VEGA DE OPL, DIJO:-----

Que adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el Señor Vocal de Primer Voto, en consecuencia voto en igual sentido.-----

En su mérito,-----

SE RESUELVE:-----

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto, debiendo confirmarse el decisorio de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravios, con la salvedad de lo atinente a la imposición de costas atribuida a la codemandada María Marta Gabriela Berisso, la que debe ser eximida de las mismas.-----

2) Costas en esta Sede a cargo de la parte vencida.-----

3) Regular los honorarios al Dr. Ricardo Javier Mancini en el 35% de la escala media del art. 34 de la ley 8226 (arts. 34, 36, 37 y conc. de la ley 8226).-----

4) No regular los honorarios al Dr. Mario Mangiante atento lo dispuesto por el art. 25 de la ley citada.-----

PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-

